



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעים:

1. טלי לוטן
2. נציגות הבית המשותף רחוב אמיר גלבוע וישה חפץ 9 תל אביב
3. עו"ד שני כהן
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד אלון גולן
- מרחוב אבא הלל 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים:

1. גד יד נכסים בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד עופר יובל
- מרחוב תובל 13 רמת גן

2. הרי עגו
- ע"י ב"כ עוה"ד יניב גביש
- מרחוב ברקוביץ 4 תל אביב

התובעת שכנגד:

- גד יד נכסים בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד עופר יובל
- מרחוב תובל 13 רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעת שכנגד:

- נציגות הבית המשותף רחוב יאשה חפץ 9 תל אביב
- ע"י ב"כ עוה"ד אלון גולן
- מרחוב אבא הלל 7 רמת גן

פסק דין

תביעה זו הינה אחת מבין הליכים רבים אשר התנהלו ומתנהלים בין הנציגות ובעלי דירות בבית לבין הנתבעת 1 בנוגע לבית ברחוב אמיר גלבוע וישה חפץ 9 תל אביב. בהליך דנן המחלוקת שבין הצדדים מתמקדת בסוגיית מערכת מינדוף לנכס המסחרי שבבעלות הנתבעת 1 ובפיר האוורור הקיים בבית.

תמצית טענות הצדדים בכתבי הטענות.

1. בכתב התביעה טענה התובעת כי בנכס הנתבעת 1 מפעיל הנתבע 2 פיצרייה. הנתבעים פערו חור בתעלת האוורור של שירותי אורחים של הדירות בבית וחיברו לה תעלת מינדוף אשר מובילה את ריחות האפייה מבית העסק אל תוך הדירות השונות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת טענה כי לשטח המסחרי חייב להיות פתרון מינדוף נפרד ומוגן אש ומוגבה מעל גובה הבית. תעלה כזו לא נבנתה בשל מגבלות תכנוניות. החיבור לתעלת האוורור של הבית מסוכן במקרה של שריפה, נעשה בניגוד לדין ולתקנון הבית. משכך עתור התובעים לחייב את הנתבעים לסלק את חיבור המינדוף לתעלת האוורור ולסתום את החור שפערו.

2. בכתב ההגנה טענה הנתבעת 1 כי התובעים פועלים בחוסר תום לב ומבקשים למנוע ממנה בכל דרך את השימוש בנכס המסחרי שבבעלותה. מאחר ופיר האוורור הינו רכוש משותף הרי שגם הנתבעת זכאית לעשות בו שימוש. הסגת הגבול הינה של בעלי הדירות בבית אשר חדרי השירותים שלהם פונים לפיר האמור ולא של עסק הנתבעת 1. הפיר האמור נועד לאוורור של השטח המסחרי על פי היתר הבניה ועל פי בנייתו בפועל – מיקומו, בדיוק מעל הפיצרייה, ויעודו במקור, הינם עבור שימוש זה. דווקא חיבור חדרי השירותים של הדירות באמצעות מפוחים נעשה שלא כדין על פי יעודו המקורי של הפיר. אין כל הגבלה על השימוש המסחרי המותר בנכס הנתבעת 1. בכל מקרה, השימוש בפיר הינו שימוש סביר כאשר מדובר בבית בו שימושים מעורבים, לאור מיקומו של הפיר ומטרת בנייתו, לאור השימוש שעושים בו בעלי דירות אחרים ולאור העובדה כי השימוש אינו גורע מאיש. אין בשימוש כאמור גם גריעה מהוראות סעיף 2 לתקנון המצוי – אין כל הוראה חוקית האוסרת את חיבור מנדף הפיצרייה לפיר האוורור, לרבות לא בביקורות רישוי עסקים שנערכו. אין כל ראייה להפרעה כלשהי או מטרד ריח, ודאי כאשר הוצאת האוויר מחדרי השירותים של הדירות לפיר היא באמצעות ונטה חד כיוונית. המפוחים שהיו אמורים להיות מותקנים על הגג אמורים היו למנוע כל חדירה של ריחות וככל שישנו ריח הרי שהוא נובע מביצוע לקוי של הפיר. בהיתר הבניה נכללה חובה לבנות ארובה מהשטח המסחרי לגג הבית והנתבעת עומדת על זכותה להתקין ארובה כזו ככל שיהיה לכך צורך לשם קבלת רישיון עסק.

3. ביחד עם כתב ההגנה הגישה הנתבעת 1 גם תביעה שכנגד בה טענה כי יעוד הפיר הינו לשטח המסחרי, כי הפיר הינו רכוש משותף בו זכאית גם הנתבעת לעשות שימוש, כי התקנת הארובה בפיר מהווה שימוש סביר על פי ייעודו של הפיר והתקנה זו לא תפגע בערך הדירות, כי הסכם השיתוף מתיר שימוש ללא כל הגבלה בשטח המסחרי, כי מניעת התקנת הארובה תסכל את זכויות השימוש של הנתבעת וכי חובת תום הלב מחייבת את בעלי הדירות בבית לאפשר פתיחת פתחים אל פיר האוורור.

4. בהתאם לטענותיה כאמור עתרה התובעת שכנגד למתן סעדים כלהלן – מתן צו הצהרתי כי בכפוף לקבלת היתר בניה היא רשאית להתקין ארובה בפיר האוורור הקיים מהשטח המסחרי עד לגג הבית; מתן צו הצהרתי לפיו היא רשאית לפתוח פתחים ופתחי שירות לארובה מלובי הקומות מבלי שיהיה בדבר לפגוע ברכוש המשותף או בשימוש; לחייב את הנתבעת שכנגד לאפשר גישה ללובי הקומתי ולפיר האוורור; לאסור על הנתבעת שכנגד ובעלי הדירות להפריע בביצוע עבודות להתקנת הארובה.

5. בכתב ההגנה שכנגד נטען כי הפעלת הפיצרייה מהווה הפרה של הוראות חוק המקרקעין, דיני התכנון והבניה ואיכות הסביבה. הוכחה הטענה בדבר יעודו של הפיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

או טענת השימוש הסביר של התובעת שכנגד, ודאי כאשר יש בכך הפרה של הוראות התקנון המצוי והחלטת בעלי הדירות אשר אוסרת על הצבת מתקנים ברכוש המשותף. בבית לא תוכננה ארובה בשל מגבלות תעופה אזרחית המונעות התקנה של כל מתקן מעל לגובה מעקה הגג. התובעת שכנגד יכולה להפעיל כל עסק בשטחה אך בכפוף למגבלות הדין ומבלי לפגוע בבעלי הדירות בבית. אין למפקח סמכות לאפשר לתובעת להתקין ארובה או לחייב את בעלי הדירות להסכים לבנייה שכזו. אין למפקח גם סמכות לדון בסוגיות הקשורות בחוק התכנון והבניה. בהעדר היתר לבניית ארובה אין מקום כלל להיזקק לתובענה.

6. בכתב ההגנה של הנתבע 2 טען האחרון כי הוא מפעיל את העסק ביחד עם אחרים, כי הוא קיבל את הנכס כפי שהוא ולא ביצע בו כל פעולה, כי לא מבוקש כנגדו כל סעד במסגרת ההליך ובנסיבות יש להורות על דחיית התביעה כנגדו.

ההליכים שהתנהלו, הסכמת הצדדים וחוות דעת המומחה

7. ביום 23.05.17 נערך דיון מקדמי בהליך במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה לפיה ימונה מומחה מטעם המפקח אשר ימסור חוות דעתו בנוגע לסוגיות שהוגדרו על ידי הצדדים וכי לאחר קבלת חוות הדעת והגשת סיכומים מטעם הצדדים אפסוק בתובענה.

8. הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של החלטה ובמסגרתה נקבע כי היא מחייבת גם את הנתבע 2 אשר לא התייצב לדיון. יוער, כבר עתה, כי הנתבע 2 בחר גם שלא להגיש סיכומים מטעמו במסגרת ההליך העיקרי בהתאם להחלטותיי.

9. על פי הסכמת הצדדים מונה בהחלטתי מיום 25.05.17 מר משה בן צבי כמומחה מוסכם.

10. ביום 31.07.17 הוגשה חוות דעת המומחה במסגרתה, לאחר ניתוח מפורט, השיב המומחה לשאלות שהוצגו בפניו על ידי הצדדים. בין היתר קבע המומחה כי ניתן להתקין ארובה בתעלת האוורור בהעדר חלופת מנדוף אחרת לבית העסק, כי מערכת המנדוף הקיימת כיום בפיצרייה איננה תקנית, כי אין חלופת מנדוף אשר איננה כוללת התקנת ארובה, כי אין פתרון להתקנת מערכת מנדוף ללא התחברות לפיר האוורור וכי הפיר תוכנן בעיקר עבור החנויות המסחריות.

11. בהמשך לחוות דעת, על פי הסכמת הצדדים והחלטותיי סיכמו הצדדים את טענותיהם כמפורט להלן.

12. אזכיר כי ראשיתו של ההליך בבקשה למתן צו מניעה זמני בתיק ב"ב 5/206/17 אשר נמחקה לאחר דיון במעמד הצדדים ביום 26.03.17. בהמשך הוגשה בקשה נוספת למתן סעד זמני בתיק ב"ב 5/744/17, לאור ובעקבות חוות דעת המומחה. בקשה זו נדחתה בהחלטתי מיום 25.09.17.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הצדדים הסיכומים

סיכומי התובעים

13. התובעים טענו כי המומחה אישר את טענתם לפיה מערכת המנדוף שהותקנה איננה תקנית, כי נדרשת התקנת ארובה וכי קיימת מגבלת גובה, כי חיבור המנדוף גורם מטרד ומהווה סכנת חיים. קביעות המומחה בנוגע למחדלי התכנון ורשלנות בעלי המקצוע אינן בתחום מומחיותו ואינם נדרשים לשם הליך זה. חיבור המנדוף, כפי שבוצע, איננו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף ויש להסירו.

14. נטען עוד כי הנתבע 2 נטש את מקום העסק ובמועד כתיבת הסיכומים הפיצרייה נטושה ואיננה פועלת.

סיכומי הנתבעת/התובעת שכנגד

15. בכל הקשור לתביעה העיקרית טוענת הנתבעת כי סיכומי התובעים אינם מלמדים על כל בסיס לעילת התביעה שהוגשה – הסגת גבול והפרת הוראות סעיף 2 לתקנון המצוי. טענות במישור התכנוני, רישוי או מטרד אינן בסמכות המפקח. הדיון הנדרש הינו קנייני בלבד וכאן מבקשת התובעת שכנגד להקדים את הבירור הקנייני בטרם ההליך התכנוני לאישור הארובה הנדרשת. חוות הדעת תומכת בטענות הנתבעת ובכך כי השימוש אותו היא עושה הינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף – תעלת אוורור אשר נועדה במקור לטובת בית העסק. ממצאי המומחה מגלים ליקויים משמעותיים בפיר האוורור המרכזי, חריגה מהתכנון המקורי להתקין ארובה והעדר התמודדות אפשרית עם סוגית מגבלת הגובה (בתכנון המקורי ולאחר מכן). לאור ממצאי המומחה הרי שתעלת האוורור נועדה לשימוש השטח המסחרי ולכן שימוש זה תואם את זכויותיה הקנייניות הנתבעת 1 רשאים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף אשר נועד לאוורור נכסיה, השימוש אינו מונע שימוש דומה מאחרים והמומחה מאשר כי ניתן לבצע שימוש מקביל על ידי השטח המסחרי ובעלי הדירות. שאלת עמידת מערכת המנדוף בתקן אין בה להעלות או להוריד בשאלה הקניינית הנדרשת להכרעה. אין קביעה בדבר סכנה מהמערכת הקיימת וגם לא קביעה כי המערכת איננה תקנית אלא אך פתרון להסדרה. הבית נבנה לשימושים מעורבים, לרבות עבור בית אוכל בנכס הנתבעת, האיזון הקנייני אינו יכול להביא למניעת שימוש הנתבעת בנכס שבבעלותה בשל פגיעה אפשרית בחלק מהדירות בבית. מניעת ריחות מוחלטת איננה נדרשת באיזון הקנייני. מכל מקום מדובר בטענת מטרד שאיננה בסמכות המפקח.

16. בכל הקשור לשימוש בבית העסק נטען כי הנתבע 2 הפסיק להפעיל את הפיצרייה בשל מחלוקת בין השותפים בעסק. כיום צד שלישי מפעיל את בית העסק.

17. בכל הנוגע לתביעה שכנגד הרי שהמומחה מאשר באופן ברור כי יש להתקין ארובה בפיר שנבנה למטרה זו כאשר התקנה זו גם אפשרית, לאחר קבלת היתר בניה כדון,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מבלי לפגוע כלל ברכוש המשותף או בדירות. מניעת התקנת הארובה תסכל אפשרות השימוש בנכס בניגוד לתכנון המקורי ולזכויות הקנייניות של התובעת שכנגד.

סיכומי הנתבעת שכנגד

18. לאור חוות הדעת הרי שהתקנת המנדף הקיים איננה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף – החיבור אינו תקני, גורם למטרד ריח ומהווה סכנת חיים. כל קביעה אחרת תביא לכך שכל דאלים בבית יגבר. ללא ארובה, שהליך לגביה יארך עוד זמן רב, אם בכלל, השימוש כיום אינו סביר. פעולת הנתבעת מהווה גם הפרה של הוראת סעיף 2 לתכנון ובגדר "פצצה מתקתקת". לא ניתן לאשר פתיחת פתחים בלובי הקומתי ללא אישור האסיפה הכללית לאור היות האמור בגדר פגיעה ברכוש המשותף, הנתבעת 1 היתה חלק מיזמי הבית והיא זו שלא פעלה לקבלת האישורים מהגורמים המוסמכים בנוגע לבניית הארובה, אין היא יכולה לפיכך לכפות שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף. נטען עוד כי הנציגות איננה הגוף המוסמך להתיר או לאסור שימושים בשם בעלי הדירות ובהתאם גם לא להתיר התקנת ארובה. את ההליכים הקשורים בתביעה שכנגד יש לנהל מול בעלי הדירות.

דיון והכרעה

התביעה העיקרית

19. בטרם נכנס לגופו של דיון בתובענה אני מוצא לנכון להורות על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 2.

ראשית, על פי סיכומי הנתבעת 1 הרי שהנתבע 2 אינו מפעיל עוד את בית העסק. כך גם עולה מסיכומי התובעת עצמה.

שנית, טענת הנתבע 2 בכתב ההגנה כי לא ביצע כל פעולה ברכוש המשותף וכי קיבל את הנכס, כפי שהוא, לא נסתרה על ידי מי מהצדדים האחרים בהליך, ולמעשה גם לא נטען אחרת.

שלישית, מכתבי הטענות וההתנהלות בהליך זה הרי שהנתבעת 1 גם נטלה על עצמה את האחריות בכל הקשור לפעולות הנכס שבבעלותה, ודאי כאשר עתה, לטענתה, מפעיל צד שלישי אחר את בית העסק, לאחר שהליך זה כבר מתנהל.

20. בנסיבות בהן הנתבע 2 הגיש כתב הגנה מטעמו והתייצב לדיון בבקשה למתן צו סעד זמני, אך לא התייצב לדיון בהליך העיקרי ולא הגיש סיכומים מטעמו, אני קובע כי אין צו להוצאות בתובענה כנגדו.

21. עתה להכרעה לגופה של התובענה העיקרית. אפתח כבר בסיומם של דברים ואבהיר כי מצאתי מקום בנסיבות דנן לקבל את התביעה העיקרית ולחייב את הנתבעת להסיר את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חיבור המינדף הקיים לתעלת האוורור ולסתום את החור בתעלת האוורור תוך החזרת מצב הפיר לקדמותו. ואלה הם נימוקיי.

22. לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

23. אין מחלוקת כי בידי הנתבעת אין אישור האסיפה הכללית להתקנת מערכת המינדוף הקיימת ובכלל האמור פריצת פתח מהנכס לפיר המשותף. בהתאם, עלינו לבחון התקיימות התנאים המזכים את הנתבעת לבצע, ללא כל אישור כאמור, את פעולת הפריצה וההתקנה.

24. אני מוכן להניח לטובת הנתבעת כי התקנת המערכת תוך פריצת הפתח לפיר המשותף איננה מונעת שימוש דומה מאחרים לאור המיקום הפיזי של הפיר מעל לבית העסק כפי שתיאר המומחה. אולם, ההתקנה כאמור איננה יכולה לעמוד במבחני המקום והזמן שקבעה הפסיקה בנסיבות הקונקרטיות של הבית דנן.

25. ראשית, הקביעה הברורה של המומחה הינה כי מערכת המינדוף הקיימת איננה תקנית (בסעיף 5.2 לפרק הסיכום). ויודגש, תשובת המומחה כאמור ניתנה לשאלה שנוסחה – "האם מערכת המינדוף הקיימת כיום בפצירה עומדת בדרישות התקן, לרבות, איכות סביבה כיבוי אש וכיוצא בזה". כלומר, מדובר במערכת שאיננה עומדת לא רק בתקני איכות סביבה אלא גם בתקני כיבוי אש! לא ניתן לקבל מצב שבו פעולה פיזית, שאיננה תואמת דרישות בסיסיות של תקינות בטיחותית, שמבצע בעל דירה באופן עצמאי ברכוש המשותף תחשב כ"שימוש סביר ברכוש המשותף". תנאי המקום והזמן מחייבים כי שימוש סביר ודאי צריך שיהיה כזה שאינו מעמיד את הדירות והבית בסכנה.

26. גם המומחה מאשר, למעשה, כי לא ניתן להותיר את המצב הקיים ובחוות דעתו הוא מציע "פתרון אפשרי שימנע תלונות על ריחות בדירות ובמרפסת קומה א' ויאפשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפעלת הפיצרייה" (עמוד 2 לחוות הדעת). ויודגש, פתרון זה מוצע ע"י המומחה לאחר תיאור המצב הלא תקין הקיים כיום במערכת המנדוף המותקנת.

27. לכך יש להוסיף כי, אומנם, המומחה אינו קובע כי מערכת המינדוף היא זו אשר יוצרת את הסיכון בחדירת עשן לדירות בקומות העליונות אלא שיטת האוורור שנבחרה ובוצע במקור בעת בניית הבית (עמוד 6 לחוות הדעת). אולם, יצירת פתח מינדוף מסחרי, לא תקני, מבית עסק פעיל לפיר המשותף ללא ארובה מגדיל את הסיכון הבטיחותי הקיים לדירות האחרות בבית במקרה של שריפה. ודאי נכונים הדברים כאשר בית העסק כולל פעולות אפיה אשר מעצם טיבן מגבירות את הסיכון לשריפה ככלל ולעשן בפרט (אף בהעדר שריפה). ויודגש, מעצם טיבה של מערכת המנדוף עבור השימוש המסחרי לפיצרייה הרי שבהעדר ארובה עד לגג הנזק הפוטנציאלי לבעלי הדירות בשל העשן מועצם.

28. שנית, המומחה מאשר כי הפעלת הפיצרייה ללא מערכת מנדוף מחוברת לארובה תגרור תלונות על ריחות בדירות ובמרפסת קומה א'. אומנם, ישנו פתרון המוצע על ידי המומחה. אולם, במסגרת ההליך העיקרי אנו עוסקים במערכת המותקנת כפי שהיא כיום, וככזו מאשר המומחה במפורש כי היא גורמת לריחות ולמטרדים (ר' בעמוד 2 - סעיף 4 לתיאור מצב קיים וכן סעיף 3 לפרק הסיכומים בעמוד 7 לחוות הדעת). שימוש סביר מעצם טיבו וטבעו אינו יכול להיות כזה אשר גורם לנזקים לאחרים.

29. שלישית, אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כי בנסיבות דנן גוברת זכותה הקניינית להפעיל את בית העסק על פני זכותם של בעלי הדירות האחרים שלא לסבול ממטרדי ריחות.

ראשית, מטרדי הריחות הינם אך כתוצאה מפעולה חד צדדית של הנתבעת ולא בשל בנייתו במקור של הבית. העדפת זכויותיה של הנתבעת בהקשר כזה יהיה בהן משום מתן לגיטימציה לכל בעל דירה לבצע כל פעולה עצמית ברכוש המשותף אף אם יש בה כדי לשנות מצב קיים ולפגוע בבעלי דירות אחרים בבית.

שנית, וזה העיקר, מחוות דעת המומחה עולה כי קיימת בידי הנתבעת חלופת מנדוף שניתן לאשרה ולבצעה באופן חוקי ומבלי שיהיה בדבר פגיעה או מטרד בבעלי הדירות האחרים (ר' סעיף 2 לפרק הסיכום בחוות הדעת). במקרה שכזה האיזון נוטה בבירור לטובת מניעת הפגיעה בבעלי הדירות עקב שינוי חד צדדי שבוצע על ידי הנתבעת ברכוש המשותף הקיים בגמר הבניה.

שלישית, הנתבעת לא ניסתה ולא עשתה כל מאמץ למניעת הריחות והמטרדים. בהקשר זה היא פעלה ברכוש המשותף כבשלה תוך התקנת מערכת אותה בחרה בעצמה, ללא הסכמה, ללא הודעה, באופן לא תקני כאשר ברור לכל, גם לנתבעת עצמה, כי מערכת זו אין בה די בהעדר ארובה עד לגג הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. אולם, מעבר לאמור הרי שלאור חוות הדעת הוכח כי פעולת הנתבעת ברכוש המשותף – פריצה לפיר המשותף לשם התקנת מערכת המינדוף – מהווה פעולה העומדת בניגוד להוראות סעיפים 2(א) ו-2(ב) לתקנון המצוי.

31. בטרם נבחן הנסיבות הקונקרטיות של המקרה דנן נזכיר כי על פי הפסיקה יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת ביותר. כך נפסק כבר בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא". כך פוסק בית המשפט גם בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם" (ר' גם ע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 וכן ע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444).

32. בנסיבות דנן המומחה מאשר כי הנתבעת ביצעה פעולה פיזית של פריצת פתח בתחתית פיר האוורור והתקינה מערכת מנדוף בשטח הפיר ברכוש המשותף עם ארובה קצרה (עמוד 2 לחוות הדעת - סעיף 1 לתיאור מצב קיים). אף שאין מדובר ב"קיר חיצוני" הרי שמדובר עדיין בפיר המהווה רכוש משותף שבשלמותו ובתקינותו פגעה הנתבעת בפעולתו. בהתאם להלכות שלעיל די בכך כדי להביא לקבלת התביעה.

33. זאת ועוד. סעיף 2 לתקנון אוסר על בעל דירה לעשות שינויים בדירתו אשר "פוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו" ובהתאמה שינויים אשר "פוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה".

34. המומחה אישר כי מערכת המנדוף הקיימת איננה תקנית, כי קיימת סכנה בטיחותית (אשר מוחמרת כאמור לאור פתיחת הפתח מבית העסק של הנתבעת) וכי קיימים מטרדי ריחות כתוצאה מהתקנתה של מערכת המינדוף הקיימת. די באלו כדי שהתובעים יעמדו ברף ההוכחה הנדרש בהליך האזרחי כדי לבסס, לכל הפחות, את הטענה כי הפעולה "עשויה לשנות" את ערכה של דירה אחרת בבית המשותף או של הרכוש המשותף.

35. גם אין מדובר בפעולה של "מה בכך" שבוצעה על ידי הנתבעת מבחינת משמעותה - מדובר בהתקנה בניגוד לתקן של מערכת מינדוף לנכס מסחרי תוך גרימה של מטרדים לבעלי הדירות האחרים בבית וכאשר ברור לכל, גם לנתבעת עצמה, כי אין די במערכת זו (שממילא לא אושרה על ידי כל גורם מוסמך, לרבות, איכות סביבה). אף אם יש צדק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בטענות הנתבעת כי יש לאפשר לה להתקין מערכת מינדוף תקנית (ולכך עוד נתייחס להלן במסגרת התביעה שכנגד), אין הדבר מקים בידה את הזכות לבצע פעולות חד צדדיות תוך גרימת נזקים לרכוש המשותף ולבעלי הדירות.

36. ויודגש, לא יכולה להיות מחלוקת כי פעולות הנתבעת גרמו לנזקים לבית על פי מצבו הפיזי הקיים של הבית, בין אם נבנה על פי הדין ובין אם לאו. טענות של הנתבעת כנגד מקימי הבית, מכוח הסכם השיתוף או מכוח דיני התכנון אין בהן להשליך על ההכרעה הקניינית כאמור אשר מתבססת על מצבו של הבית ב"גמר הבניה".

37. ההלכה קובעת בהקשר זה כי "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (ר' פרשת אליאס, לעיל). הדברים נכונים שבעתיים בנסיבותיו של הבית דנן ולאור מכלול ההליכים שבין הצדדים, כפי שהם עצמם טרחו לשוב ולהזכיר בכתבי הטענות מטעמם.

התביעה שכנגד

38. לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים ולאור חוות דעת המומחה אני מוצא לנכון לקבל את התביעה שכנגד בחלקה וכפי שיפורט להלן.

39. לאור מסקנותיו הברורות של המומחה הרי שניתן להתקין ארובה לנכס המסחרי דרך פיר האוורור ובכלל האמור לשם כך נועד הפיר. המומחה מציע פתרון מנדוף אשר יש בו למנוע ריחות לבעלי הדירות ולאפשר שימוש בפיר הן לשם מנדוף לנכס המסחרי והן לשם אוורור חדרי השירותים בדירות, כפי שקיים המצב כיום בבית (ר' מסקנות המומחה בפרק הסיכום לחוות הדעת בעמוד 7 ובפרט תשובותיו לשאלות המפורטות בהסכמת הצדדים (סעיף 5)).

40. לאור הסכמת הצדדים כי ההכרעה בתובענות תינתן לאחר קבלת חוות דעת המומחה ובנסיבות בהן קביעותיו של המומחה בנוגע לפיר האוורור ופתרונות המנדוף ברורות וחד משמעיות כאמור, הרי שהתובעת שכנגד זכאית לסעד הצהרתי אשר יקבע כי התקנת ארובה בפיר האוורור, בהתאם להיתר בניה, על פי דרישת כל תקן ודין אחרים ועל פי הנחיות המומחה בחוות דעתו, הינה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. בכלל האמור לשם התקנה כאמור רשאית התובעת שכנגד לשוב ולפתוח פתח מהנכס שבבעלותה לפיר המשותף לאחר קבלת היתר וכל אישור נדרש אחר.

41. ויודגש, למעשה, הנתבעת שכנגד איננה חולקת על זכותה הקניינית בהקשר האמור של התובעת שכנגד, בכפוף לקיום הליכי הרישוי הנדרשים (ר' סעיף 16 לסיכומים).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. אולם, לאור העובדה כי נכון לעת הזו אין כל קונקרטיות לארובה שהתקנתה מבוקשת, למרות המלצות המומחה, ובכלל האמור לא הוגש כלל היתר בניה וממילא אין כל אישור להתקנת הארובה, הרי שאין מקום ליתן את הסעדים האחרים המבוקשים בהקשר זה – מדובר בתביעה תיאורטית בכל הקשור לסעדים האופרטיביים המבוקשים בה.

43. ודאי אמורים הדברים כאשר גם על פי חוות דעת המומחה יש לפעול תחילה לקבלת אישורים של גורמים שלישיים לשם התקנת הארובה, לרבות, בהתייחס למגבלות גובה שונות (סעיף 1 לפרק הסיכום בעמוד 7 לחוות הדעת) ולאיוכות סביבה (סעיף 2 לפרק הסיכום בעמוד 7 לחוות הדעת), בטרם ניתן יהיה לדון בכלל בהשלכות הפיזיות הקשורות בהתקנת הארובה.

44. בכלל האמור ברי כי אין מקום ליתן צו הצהרתי, שאינו מבוסס על כל מפרט קונקרטי (אם וככל שיאושר), לפיו התובעת שכנגד רשאית לפתוח פתחים כלשהם לארובה מלובי הקומות או מכל מקום אחר בבית המשותף, למעט מהנכס שבבעלותה כאמור.

45. ויודגש, גם התובעת שכנגד מודעת לכך כי אין בידה לבצע פעולות אשר פוגעות ברכוש המשותף או בשימוש בו (ר' במפורש הסעד המבוקש בסעיף 2.2 לכתב התביעה שכנגד – "ושלא יפגע ברכוש המשותף או בשימוש בו על ידי דיירי הבניין"). בהעדר קונקרטיות כלשהי לסעד המבוקש – אילו פתחים? היכן? גודלם? כיצד יסגרו? מהיכן הגישה? וכיוצ"ב שאלות בסיסיות אחרות - לא ניתן לקבוע עתה אם בהתקנה עלומה של ארובה כלשהי, שלא ברור מה טיבה ואופייה, יש משום פגיעה כאמור.

46. כנ"ל אמורים הדברים בכל הקשור לבקשה לחייב את הנתבעת שכנגד לאפשר גישה ללובי הקומתי ולפיר האוויר לצורך התקנת הארובה, שוב, כאשר איננו יודעים כלל אם תתבקש התקנת ארובה, אם זו תאושר, וככל שתאושר באיזה מתווה, אילו עבודות ואילו גישה ידרשו.

47. סופו של דבר אומנם, לאור חוות דעת המומחה, אפשרית התקנת ארובה בפיר כאמור. אולם, התובענה שכנגד הקדימה את זמנה בהעדר תכנון קונקרטי ואיננה מזכה את התובעת שכנגד בקבלת כל סעד אופרטיבי שהתבקש.

48. אין בידי גם לקבל את התובענה המבקשת לאסור על הנתבעת שכנגד ובעלי הדירות להפריע בביצוע עבודות להתקנת הארובה - ראשית, כאמור, כל עוד לא אושרה ארובה במתווה קונקרטי ממילא אין בידה של התובעת שכנגד כל זכות אופרטיבית, למעט ההצהרה הכללית כמפורט בפרק הסיכום בפסק דין זה; שנית, נציגות הבית איננה יכולה להיות מחויבת בצו מניעה אשר אוסר עליה "הפרעה" - הנציגות הינה, אומנם, אישיות משפטית, אך אין היא יכולה "להפריע" פיזית - צו כאמור ניתן לתת רק כנגד אנשים "בשר ודם". דא עקא, כאלו לא נתבעו כלל במסגרת התביעה שכנגד וממילא לא ניתן לחייב בדבר מי שאינו צד להליך משפטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. לפני סיום נכון יהיה להתייחס לטענות ההדדיות של הצדדים, ובעיקר התובעת שכנגד, בנוגע לחוסר תום הלב של הצד האחר.

50. אין לי אלא להצטער על הדרך בה בחרו הצדדים להתמודד האחד עם השני באמצעות נקיטת הליכים משפטיים חוזרים ונשנים. נקבע כבר כי החובה לנהוג בהגינות ובתום הלב חלה גם על בעלי דירות בבית משותף (ראה בעניין זה ע"א 2896/90 טרזקי ואח' נ. דיין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454). לצערי, שני הצדדים תרמו יחדיו, בהתנהלות בלתי הגונה ולא מתחשבת, להעמקת הסכסוך בניהם. כך גם כאן - מחד, חוסר הגינות קיים מצידה של הנתבעת 1 בהתקנת מערכת מנדוף לא תקנית אשר גורמת לנזקים לבעלי הדירות וזאת ללא התייעצות, ללא בדיקה ומתוך מחשבה על עצמה בלבד, במטרה להפעיל את בית העסק בנכס, "ויהי מה". מאידך, גם התובעים לא פעלו למציאת פתרון מנדוף אחר, מקובל על הגורמים המקצועיים, על הנתבעת ועל בעלי הדירות, אשר יביא לאפשרות הפעלת בית העסק מבלי לגרום נזק לבעלי הדירות או לבית. פתרון כאמור קיים כפי שנקבע בחוות הדעת ואמור היה להיות גם מיושם. התעקשות, חוסר התחשבות והתעלמות מצרכים הדדיים הביאה את הצדדים והבית לסכסוך הכולל ולהליכים משפטיים רבים. ההכרעה כאמור בפסק דין זה מאזנת את הזכויות הקנייניות של כל הצדדים בבית ומנטרלת את התנהלות הצדדים כאמור.

סיכום

51. לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

52. אני מקבל את התביעה העיקרית ומחייב את הנתבעת לסלק את מתקן המינדוף המותקן בפיר האוורור בבית ובכלל האמור לאטום את הפתח שפתחה מהנכס שבבעלותה לפיר האוורור ולהשיב את מצב הפיר לקדמותו.

הנתבעת תבצע את האמור על חשבונה, באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומיומנים ובתיאום עם הנציגות בתוך 21 יום מהיום.

53. התביעה כנגד הנתבע 2 נמחקת ללא צו להוצאות.

54. אני מקבל את התביעה שכנגד בחלקה ומצהיר כי התקנת ארובה על פי היתר בניה (אם וככל שיתקבל), בהתאם להוראות כל דין החל על התקנת הארובה ועל פי הנחיות המומחה בחוות דעתו, הינה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף בבית דן.

55. בהעדר קונקרטיות בנוגע לסעדים האחרים המבוקשים בכתב התביעה שכנגד, שעה שלא התקבל היתר בניה להתקנת ארובה, ובקשה בהקשר זה אפילו לא הוגשה, הרי שאין מקום ליתן איזה מהסעדים האופרטיביים המבוקשים והתביעה שכנגד בהקשר זה נמחקת. ודאי אמורים הדברים בנוגע לסעדים המבוקשים כנגד בעלי הדירות בבית שאינם כלל צד להליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/205/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למען הסר ספק ככל שיתקבל היתר בניה בידי התובעת שכנגד להתקנת ארובה (וטענות מי מהצדדים במישור התכנוני, ובכל היבט קשור אחר שמורות להם) וככל שתידרש עוד הכרעה בסוגיות הקשורות בהתקנת הארובה, הרי שתוכל התובעת שכנגד לעתור בתובענה מתאימה לכשיגיע המועד.

56. בנסיבות בהן התקבלה התביעה העיקרית במלואה והתביעה שכנגד בחלקה, ובהתחשב בבקשות הביניים שהוגשו, ובכלל האמור דחיית שתי בקשות של התובעים לקבלת סעדים זמניים, אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך, לרבות, בכל הקשור להוצאות המומחה בן צבי.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' תשרי תשע"ח, 28 ספטמבר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין